

1501145-77.2021.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARISE TERRA PINTO BOURGOGNE DE ALMEIDA

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/01/2022

... esposa não tem qualquer participação no tráfico de drogas e que a droga encontrada estava com ele e é de sua responsabilidade apenas. (fls. 12)

Em juízo admitiu novamente o tráfico, esclarecendo que os fatos ocorreram exatamente como informado pelos guardas civis municipais, estando a droga e o dinheiro em uma sacola em suas mãos.

A confissão judicial do réu é corroborada ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

5ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, São José dos Campos-SP - cep 12246-260

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501145-77.2021.8.26.0617 - Controle nº 2021/000694

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

RAFAEL DE SOUSA PAULA

Réu Preso

Juíza de Direito: Dra. Marise Terra Pinto Bourgogne de Almeida

Vistos.

RAFAEL DE SOUSA PAULA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 19 de agosto de 2021, por volta das 20h00min, na altura do nº 288 da Avenida Arthur Antônio dos Santos, no Jardim Morumbi, nesta cidade e Comarca, teria sido surpreendido por guardas civis municipais vendendo e trazendo consigo, com a finalidade de vender a terceiros para consumo, 16,50 g (dezesesseis gramas e cinquenta centigramas) da droga Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha; 3,10 g (três gramas e dez centigramas) da droga vulgarmente conhecida como cocaína, na forma de pó, e 1,75 g (um grama e setenta e cinco centigramas) da droga vulgarmente conhecida como cocaína, na forma de pedras de "crack", conforme Laudo de Constatação Provisória e Laudo de Exame Químico Toxicológico juntados a fls. 24/29 e 61/63, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Notificado (fls. 96), o réu apresentou defesa preliminar (fls. 100).

A denúncia foi recebida à fls. 101/102 e o réu foi citado (fls. 149).

Encerrada a fase probatória, o Ministério Público, em debates orais, pugnou pela condenação do acusado nos termos da inicial, sem qualquer benefício na aplicação da

pena.

A Defesa pediu o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e sua compensação com a agravante da reincidência, a aplicação do benefício previsto no § 4.º do artigo 33 da Lei de Drogas, bem como regime mais brando para início de cumprimento de pena e recurso em liberdade.

Relatado.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente observo que não há nulidade pelo fato da prisão ter sido efetuada por guardas civis municipais.

Conforme disposições constitucionais, a prisão em flagrante pode ser realizada por qualquer do povo, e nessa disposição se inserem os guardas municipais no exercício regular de suas atribuições que, na hipótese, exerciam suas atribuições de vigilância e verificaram a circunstância descrita na inicial, efetivando a prisão em flagrante do acusado pela prática de crime permanente depois que ele realizou uma venda.

É irrelevante o fato de não terem os guardas municipais poder de polícia. Qualquer do povo pode prender quem quer que esteja cometendo um crime. Na hipótese, trazer consigo para fins de comércio, sem autorização legal, substância entorpecente é crime permanente e, enquanto durar, legítima a ação de quem quer que seja para prender os autores, independentemente de ter ou não poder de polícia.

No caso, ainda, havia fundada suspeita para abordagem por estar o réu em ponto de tráfico, tendo feito a entrega de algo a indivíduo num veículo, permanecendo no local. Assim sendo, não há se falar em nulidade da prisão.

No mérito, a materialidade delitiva está bem provada, conforme auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/06), termos de depoimento (fls. 09/11), auto de exibição e apreensão (fls. 17), laudo de constatação provisória (fls. 24/29), laudo de exame químico toxicológico (fls. 61/63), bem como pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório.

A autoria é indubitosa em relação ao acusado.

Interrogado na fase policial (fls. 12/13), o réu confessou que estava no local dos fatos promovendo o tráfico de drogas. Disse que estava na Avenida Arthur Antônio dos Santos, Jd. Morumbi, sozinho, quando sua esposa Luiza lá apareceu. Comprou um salgado para sua esposa e ficou ali com ela por alguns instantes conversando, pois ela já iria deixar o local. Ressaltou que não realizou qualquer venda de droga próximo a sua esposa, pois tem certo de que não podia envolvê-la no "crime".

Afirmou que não havia qualquer viatura da guarda civil ou policial nas proximidades, salvo se estivessem ocultos realizando observação à distância. Em certo instante avistou uma viatura da guarda civil se aproximando, sem luzes de alerta ligadas. Falou para Luiza que os guardas estavam vindo e ficou tranquilo, no mesmo local que estava. Os guardas civis já o pararam direto, como se já o tivessem investigando, o revistaram e não localizaram qualquer droga. Em seguida, os guardas passaram a vistoriar as imediações, buscando em canos e água, lixos e monte de entulho qualquer droga. Os guardas já estavam quase desistindo, quando um dos guardas civis pediu para que retirasse o calçado. Disse que conseguiu retirar um tênis sem chamar a atenção do agente público sobre a droga que lá havia ocultado, mas ao retirar o outro tênis o volume dos quatrocentos e poucos reais chamou a atenção dos guardas e vistoriaram suas meias e tênis localizando assim a droga e dinheiro que possuía. Afirmou aos GCMS que era "peixe pequeno" e que não queria ir preso, sendo que os guardas disseram que se passasse as informações que possuía eles iriam liberá-lo. Diante disso, "passou toda a caminhada" aos guardas civis e, ao final das explicações, os guardas o algemaram e trouxeram até a delegacia. Não foi agredido pelos GCMS. Reiterou que sua esposa não tem qualquer participação no tráfico de drogas e que a droga encontrada estava com ele e é de sua responsabilidade apenas. (fls. 12)

Em juízo admitiu novamente o tráfico, esclarecendo que os fatos ocorreram exatamente como informado pelos guardas civis municipais, estando a droga e o dinheiro em uma sacola em suas mãos.

A confissão judicial do réu é corroborada pela prova colhida sob o crivo do contraditório.

Com efeito, os Guardas Municipais Cássio e Pablo, ouvidos em ambas as fases do procedimento (fls. 09/10), narraram que, na data dos fatos, por volta das 20h00, ambos ocupando a viatura placas FIY 9672, encontravam-se pela Av. Arthur Antônio dos Santos, Jd. Morumbi, quando avistaram um homem, posteriormente identificado como Rafael de Souza Paula, aproximar-se de um veículo que parou na via pública e entregar algo para o condutor do automóvel. Não foi anotado marca, modelo ou emplacamento do veículo. Na sequência o automóvel deixou o local, e Rafael, acompanhado de uma mulher, posteriormente identificada como Luiza Carla Silva Silvério, continuou por ali. Com a aproximação da viatura da guarda civil, Rafael se mostrou nervoso e por isso foi abordado e revistado. No interior da sacola que Rafael trazia em sua mão foram localizadas 10 porções de erva desidratada semelhante a maconha, 10 porções de pó branco semelhante a cocaína, 14 porções de pedriscos amarelados semelhantes ao crack, além de R\$ 401,00 (quatrocentos e um reais) em espécie. Também havia do bolso de Rafael dois aparelhos celulares. No local dos fatos, informalmente, Rafael confessou que promovia o tráfico de drogas. A testemunha Luiza Carla relatou, em solo policial, que é esposa de Rafael de Souza Paula e que havia acabado de chegar onde seu marido estava e ele comprou um salgado para ela comer, pois estava com fome. Na sequência Rafael foi abordado por guardas civis, que localizaram droga e dinheiro com ele e o trouxeram para a Delegacia. Afirmou que não tinha qualquer envolvimento ou participação nas atividades ilícitas de seu marido e não sabia que ele estava traficando ali (fls. 11). Neste contexto, os relatos seguros, coesos e detalhados dos guardas civis permitem concluir com segurança que foram encontrados entorpecentes no interior da sacola que estava em poder do réu, sendo evidente que tais drogas eram destinadas ao tráfico, tendo em vista a quantidade e forma de acondicionamento. O réu estava com drogas de tipos diversos, além de dinheiro trocado em seu poder, tendo confessado formalmente a mercancia aos guardas que o abordaram e que inclusive visualizaram uma venda e também em juízo.

Neste passo, o tráfico de drogas se confirmou em relação ao acusado, razão pela qual não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Delineada a culpa, passo à análise da pena.

Conforme se depreende da certidão de fls. 84/85, o réu é reincidente, visto que possui uma condenação anterior aos fatos (processo nº 0021020-09.2016.8.26.0577), cuja pena ainda não foi extinta. Tal circunstância será oportunamente considerada. Inicialmente, fixo sua pena no mínimo legal de 05 anos de reclusão e o pagamento de 500 dias-multa, no piso.

Na segunda fase de dosimetria da pena, em virtude da reincidência, elevo a pena em 1/6, resultando em 05 anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 583 dias-multa, no piso.

Destaco que, apesar de confesso o réu, a reincidência é circunstância preponderante, e permite o aumento de sua pena-base em 1/6.

Este entendimento, consoante dicção lapidar do art. 67, do Código Penal, é harmônico com a Constituição Federal. Precedente do Supremo Tribunal Federal (RE 453.000 - Tribunal Pleno - Repercussão Geral - Rel. Min. Marco Aurélio - j. 04.04.2013 - DJE 03.10.2013).

Inclusive, como diferente não haveria de ser, tal entendimento é refletido pela Doutrina de Luiz Flávio Gomes, Alice Bianchini e Victor Eduardo Rios Gonçalves e pela tranquila jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (HC 105.543/MS - Rel. Min. Roberto Barroso - j. 26.05.14; RHC 118.107/MG - Rel. Min. Teori Zavaski - j. 29.05.14; RHC 120.677/SP - Rel. Min. Ricardo Lewandowski - j. 01.04.14 e RHC 115.994/DF - Rel. Min. Cármen Lúcia - j. 02.04.13).

Neste sentido:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGRAVO PROVIDO" (STF ARE 873289/DF Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA j. 13.03.2015 DJe 17.03.2015);

"(...) O acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, a teor do art. 67 do Código Penal, 'a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada' (RHC 110.727, Rel.

Min. Dias Toffoli)" (STF HC 105543/MS Primeira Turma Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO j. 29.04.2014) ;

"(...) A reincidência é circunstância agravante que prepondera sobre as atenuantes, com exceção daquelas que resultam dos motivos determinantes do crime ou da personalidade do agente, o que não é o caso da confissão espontânea. Precedentes (...) A confissão espontânea é ato posterior ao cometimento do crime e não tem nenhuma relação com ele, mas, tão somente, com o interesse pessoal e a conveniência do réu durante o desenvolvimento do processo penal, motivo pelo qual não se inclui no caráter subjetivo dos motivos determinantes do crime ou na personalidade do agente" (STF RHC 115994/MS Segunda Turma Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA 02.04.2013);

"(...) Nos termos do art. 67 do Código Penal, no concurso de atenuantes e agravantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes. No caso sob exame, a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada. Precedentes" (STF RHC 120677/SP Segunda Turma Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI j. 18.03.2014).

Deixo de aplicar a benesse contida no artigo 33, parágrafo 4.º, da Lei 11343/06, pois o réu é reincidente, o que por si só já afasta tal possibilidade.

Torno a reprimenda acima definitiva à minguia de outros elementos modificadores.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu RAFAEL DE SOUSA PAULA ao cumprimento da pena de 05 anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 583 dias-multa, no piso, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

O acusado não faz jus a penas substitutivas e tampouco ao sursis em razão do tempo de pena imposto e por ser reincidente.

Pelos mesmos motivos e diante das circunstâncias do crime, bem como o comportamento e a personalidade do réu, que já foi condenado anteriormente por tráfico e voltou a delinquir, a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena é medida de rigor.

Mesmo estando preso desde 19 de agosto de 2021, tempo que será oportunamente detraído de sua pena, o regime inicial de cumprimento de pena permanece o fechado, pela gravidade e consequências do crime anteriormente mencionadas, não sendo possível imposição de regime menos severo e análise, por este juízo de conhecimento, dos requisitos subjetivos e objetivos para progressão ou outro benefício da fase executória.

Não poderá apelar em liberdade pelo regime prisional imposto e porque a ordem pública e a aplicação da lei penal devem ser garantidas, permanecendo presentes os requisitos que fundamentaram a decretação de suas custódias cautelar, notadamente após a condenação, já ostentando condenação pelo mesmo crime anteriormente.

Declaro o perdimento dos bens e valores apreendidos nos autos em favor do FUNAD, após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 63, da Lei 11.343/06.

Após o trânsito em julgado, proceda a Serventia as anotações e comunicações de praxe, inclusive à Justiça Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Sentença registrada eletronicamente.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

São José dos Campos, 26 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA